

1500722-38.2021.8.26.0320  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen  
Comarca: Limeira  
Foro: Foro de Limeira  
Vara: 3ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 14/07/2022  
... g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado, resistência e conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Limeira  
Foro de Limeira  
3ª Vara Criminal  
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500722-38.2021.8.26.0320 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500722-38.2021.8.26.0320  
Classe - Assunto:  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072969/2021 - DISE-  
DEL.SEC.LIMEIRA, 16791119 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 35/21/819 - DISE-  
DEL.SEC.LIMEIRA, 2072969 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
THAINA ELLY DORIGAN DE OLIVEIRA  
Réu Preso

Tramitação prioritária  
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

THAINA ELLY DORIGAN DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, pois, em tese, no dia 15 de março de 2021, por volta da 11h30min, na Avenida Vitório Bortolan, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, trazia consigo, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 12 (doze) porções de "cocaína", pesando 1,38g (um grama e trinta e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 191/195.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022 (fls. 206/208).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogada a acusada ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 244/250). A Defensoria Pública, por seu turno, postulou a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.340/2006, tecendo considerações subsidiárias sobre a pena (fls. 259/285).

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante da denunciada, o auto de exibição e apreensão de fls. 19, fotografias de fls. 20/21 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 77/79 e 228/230.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre a acusada, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, ouvidos em édito, os Policiais Civis Jane Aparecida da Costa e Ricardo Alfredo Coelho declararam que, na data dos fatos, estavam em uma viatura descaracterizada pelo local, conhecido ponto de venda de entorpecentes. A ré era suspeita de prática de tráfico e foi em direção à viatura, possivelmente pensando que eram compradores. A acusada foi abordada, sendo localizados papetes de "cocaína" nas duas mãos. Indagada, a denunciada alegou que eram para consumo pessoal, negando o comércio das drogas.

Em juízo, por sua vez, a acusada Thainá disse que foi ao local para comprar drogas, para fins de uso. Adquiriu 12 (doze) porções de "cocaína" e, quando estava prestes a consumir uma porção, foi abordada e detida pelos policiais.

Note-se, contudo, que o depoimento da acusada em juízo restou isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos.

Cumprido ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse

servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846). É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a informação de que o local consistia, efetivamente, em ponto de tráfico, bem como, os depoimentos dos policiais, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Diversamente do alegado pela combativa Defensoria Pública, a conduta da ré de, consoante relato dos policiais, caminhar em direção à viatura em um notório ponto de venda de entorpecentes efetivamente demonstra que seu escopo era de oferecer as drogas aos ocupantes do veículo.

Vale dizer, se a ré fosse meramente usuária, não se aproximaria do veículo em movimento, conduta típica daquele que comercializa as drogas, porém tão-somente caminharia de forma normal, seguindo seu regular trajeto, o que não se deu no caso dos autos.

Saliento, outrossim, que o fato de ser a acusada usuária não obsta a traficância, não sendo raras as hipóteses em que a venda de entorpecentes tem por escopo, além do lucro, a manutenção do próprio vício. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - Pretendida absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas - Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Condenação mantida - Pena bem dosada - Réu reincidente específico - Confissão não verificada - Exegese da súmula nº 630, do STJ - Minorante inaplicável ante a recidiva - Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado na origem - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500179-76.2019.8.26.0232; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado, resistência e conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Crime de resistência caracterizado. Disparo de arma de fogo contra os policiais. Da mesma forma, crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano configurado. Dosimetria não merece reparo. Aplicação do redutor mantida à míngua de apelo ministerial. Regime fechado bem fundamentado para o tráfico. Regime semiaberto mantido para os delitos apenados com detenção. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002419-41.2017.8.26.0537;

Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019, g.n.)

Acrescente-se que a ré ostenta antecedente criminal pelo mesmo crime de tráfico de drogas (processo nº 1504434-70.2020.8.26.0320 - fls. 181/182), o que corrobora a tese de que as porções de "cocaína" em seu poder destinavam-se ao consumo de terceiros.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, não havendo se falar em desclassificação.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são inadequadas, pois a ré ostenta antecedente criminal por tráfico de drogas (processo nº 1504434-70.2020.8.26.0320, da 1ª V. Criminal desta comarca - fls. 181/182), devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Note-se que, no referido processo, o trânsito em julgado da sentença condenatória deu-se em dia 22/11/2021, isto é, data posterior ao cometimento da infração penal do presente feito, contudo o fato foi praticado aos 02/12/2020, anteriormente à conduta desta ação, configurando-se, com isso, os maus antecedentes. Acerca do tema, confira-se:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado - como ocorre na pecha da reincidência -, senão a simples prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em julgado após os fatos do segundo processo não elimina, neste último, a consideração do primeiro crime em desabono da pessoa que o praticou. Simplesmente baliza a situação como diversa daquela típica da reincidência. No caso, o trânsito em julgado subsequente nada mais fez que definir uma conduta anterior como criminosa, todavia não foi essa coisa julgada que constituiu a má conduta, evidentemente. Assim, está-se diante um dos espaços normativos próprios da categoria dos maus antecedentes, pois indica o caso em que a pessoa pratica novo crime sabendo que já havia praticado outro anteriormente. Logo, não seria porque o trânsito em julgado desse crime antecedente ocorreu após a prática do segundo crime que, no julgamento deste último, o sujeito será tido como de bons antecedentes quando, efetivamente, não os ostentava. (TJSP; Apelação Criminal 0033114-81.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 502995/MS, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0098424-5, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento 15/08/2019, data da publicação/fonte DJe 23/08/2019, realce não previsto no original)

Oportuno anotar que em 17.08.2020, no julgamento do RE nº 593.818-SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, foi fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal a tese atinente ao tema 150 da repercussão geral, nos seguintes termos: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Nesse contexto, não há que se falar em afastamento dos maus antecedentes como pretende a combativa defesa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Deixo de reconhecer, por outro lado, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em face do mau antecedente específico, inferindo-se, pois, que, mesmo após processada criminalmente por tráfico ilícito de entorpecentes, a ré persistiu na prática delitativa, o que obsta a incidência da benesse, ainda que primária. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EREsp 1.431.091/SP, Terceira Seção do C. STJ, Rel. Ministro Felix Fischer, de DJe 01/02/2017, g.n.)

Torna-se definitiva, por conseguinte, a reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica da acusada.

Considerando os critérios norteadores e diretrizes do artigo 33, do Código Penal, malgrado a primariedade e a pouca quantidade de drogas, na espécie, o mau antecedente específico impõe a fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão, único suficiente à reprovação e prevenção delitivas.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR a acusada THAINA ELLY DORIGAN DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Inalterado o panorama fático em que decretada a custódia cautelar, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo certo que, após a concessão da liberdade por "Habeas Corpus",

conforme decisão de fls. 131/132, a denunciada deixou de atender as decisões judiciais, não sendo localizada no endereço indicado nos autos, motivo pelo qual a segregação cautelar foi novamente decretada. Nesse contexto, deve a ré ser recomendada onde se encontra recolhida, notadamente para a garantia da ordem pública e assegurar a execução da lei penal. Oficie-se.

Deixo de proceder à detração, para fins de consideração do regime inicial, pois se trata de matéria afeta ao juízo da execução. Acerca do assunto, confira-se:

Apelação. Roubo simples. Pedido defensivo requerendo, tão somente, a fixação de regime inicial mais brando, considerando-se a detração penal, e, por fim, postula pela isenção das custas processuais. Impossibilidade. Regime prisional bem fixado e que não comporta alteração. Detração que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções. Recurso defensivo não provido. (Destaque nosso, Apelação nº 0000302-54.2015.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, Rel. Des. SÉRGIO COELHO, 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 02.06.2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa pleiteia, somente, a fixação do regime semiaberto, a concessão da detração e, por fim, a isenção das custas processuais. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrado enquanto trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 220 (duzentos e vinte) pinos de cocaína, com peso líquido de 71,09 g e 15 (quinze) porções de maconha, com peso líquido de 10,35 g. Réu confesso. Provas dos autos sustentam de forma clara e robusta a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Dosimetria não comporta reparo. Basilar fixada no mínimo legal. Reincidência compensada com a atenuante da menoridade relativa mantida. Ausentes requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Regime inicial fechado adequado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Detração deve ser apreciada pelo juízo da execução. Réu faz jus à Justiça Gratuita. Hipossuficiência financeira presumida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500848-59.2020.8.26.0535; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021, g.n.)

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova.

Oportunamente, lance-se o nome da acusada no rol dos culpados.

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, já que patrocinada pela I. Defensoria Pública.

P. I. C.

Limeira, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA